



Título: Apostila Unidade 2

Autor(es): Cláudia Viegas, Paula Lara e Leonardo Poli

TEMAS DE DIREITO E INTERNET

UNIDADE 2: DIREITO AUTORAL E INTERNET

OS DIREITOS AUTORAIS:

Atualmente o Direito Autoral é reconhecido como ramo do Direito destinado à tutela das criações do espírito humano. Seu reconhecimento foi construído ao longo da história, e tem como antecedente mais remoto a invenção da imprensa, em 1455, por Gutenberg. Tal invento explicitou uma preocupação não com a tutela da obra em si, mas com a proteção dos investimentos advindos da criação intelectual.

Segundo Branco Júnior:

A invenção da tipografia e da imprensa, no século XV, revolucionou os direitos autorais porque os autores passaram a ter suas obras tornadas disponíveis de maneira muito mais ampla. Nessa época, surgem os privilégios concedidos aos livreiros e editores, verdadeiros monopólios, sem que se visasse, entretanto, a proteger os direitos dos autores.(BRANCO JÚNIOR, 2006, p. 20)

ASCENSÃO relata que, “a tutela do autor só surge com o Estatuto da rainha Ana, na Grã-Bretanha, em 1710. Então, o autor, apodera-se do privilégio da indústria” (ASCENSÃO, 2007, p. 04), sendo “a primeira norma legal que reconheceu o direito subjetivo do autor sobre sua obra, tendo-o feito como direito de propriedade”. (POLI, 2008, p. 04).

Esse Estatuto inaugurou uma fase repleta de iniciativas de lei que visavam proteger os autores, incentivando sua produção intelectual e reforçando a idéia de hegemonia dos Estados, numa disputa de inovações culturais e científicas.

Denis Borges Barbosa ensina que:

Os benefícios das leis emitidas desde 1710 para dar suporte às criações literárias, artísticas e científicas não buscavam favorecer nenhuma indústria; muito pelo contrário, sua intenção era em parte liberar os autores do poder em excesso das gráficas, em parte homenagear o valor moral da ingenuidade intelectual. (BARBOSA, 2010, p. 763)

O Direito Autoral Clássico surgiu, então, da necessidade de se proteger a criação do espírito humano, dentro de uma perspectiva liberal, em que o direito autoral estava intimamente ligado ao ideal de liberdade individual e de segurança jurídica. O Direito Autoral era visto *“simplesmente como poder atribuído ao autor com a finalidade exclusiva de se garantir a satisfação de seus interesses individuais”*.(POLI, 2008, p. 03).

Dessa maneira, o termo Direito Autoral é utilizado de duas formas:

- 1) DIREITO AUTORAL SUBJETIVO: refere-se às faculdades ou liberdades juridicamente reconhecidas ao autor sobre sua criação. Nesse aspecto, o termo é utilizado no plural, direitos autorais, aludindo à pluralidade de faculdades, poderes jurídicos conferidos ao autor.
- 2) DIREITO AUTORAL OBJETIVO: refere-se ao ramo do Direito que regula as situações jurídicas geradas pelas criações do espírito, sendo espécie do gênero Propriedade Intelectual, que também engloba a propriedade industrial.

Os direitos autorais estão previstos na Lei 9.610/98, simplesmente denominada LDA (Lei de Direitos Autorais).

O Direito Autoral brasileiro adotou a teoria dualista sobre a natureza jurídica dos direitos autorais, reconhecendo que são direitos subjetivos, mas que alguns são de caráter material (direitos patrimoniais) e outros de caráter pessoal (direitos morais de autor).

O aspecto material garante ao autor a exploração econômica de sua obra intelectual e o aspecto pessoal vincula o autor, sua personalidade, à obra que criou.

a) Direitos morais: previstos no art. 24 da LDA. São compreendidos como direitos subjetivos existenciais, pois não possuem conteúdo econômico. Ao proteger a

personalidade do autor exteriorizada na obra intelectual, o direito subjetivo existencial do autor assume um caráter personalíssimo, sendo considerado um direito da personalidade.

Art. 24. São direitos morais do autor:

I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra;

II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra;

III - o de conservar a obra inédita;

IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra;

V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada;

VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem;

VII - o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio de processo fotográfico ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memória, de forma que cause o menor inconveniente possível a seu detentor, que, em todo caso, será indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado.

Analisar-se-á alguns dos direitos morais de autor:

- **Direito de reivindicar a autoria da obra:** é o direito do autor de reivindicar, a qualquer tempo, a paternidade da obra. Este direito pressupõe um ato de violação do direito à autoria, pois ao reivindicar a autoria, o autor exerce um direito de se opor à usurpação de sua paternidade sobre a obra, sendo diferente do direito à autoria. Ex: o autor de um artigo poderá se opor à utilização de seu texto com a expressa menção do nome de terceiro como sendo o autor da obra.
- **Direito à autoria:** é o direito do autor de ter o seu nome, pseudônimo, ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização da obra. É também denominado direito de paternidade da obra, ou direito à menção do nome. Trata-se de faculdade reconhecida ao criador de tornar público o ato de criação. A LDA, em seu art. 13, prevê presunção relativa de paternidade daquele que é indicado ou anunciado como autor na utilização da obra.

- **Direito ao Inédito**: é a faculdade de o autor conservar a obra inédita. A raiz desse direito é o direito à intimidade, pois é um direito de reserva da personalidade.
- **Direito à integridade da obra**: é a faculdade do autor de se opor a qualquer modificação da obra ou à prática de qualquer ato que, de qualquer forma, possa prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação e honra.
- **Direito de modificar a obra**: é a faculdade do autor de alterar a obra a qualquer tempo, antes ou depois de utilizada. Dessa forma, somente ao autor é conferido o direito de modificação de sua criação. Observa-se que, enquanto a obra ainda é inédita não se fala em exercício de direito de autor de modificação, mas em “poder geral de criação”. Mas esse direito refere-se unicamente à integridade da criação em sua forma originária e não se confunde com a possibilidade de transformações, tais como adaptações, traduções, etc. Isso porque a transformação desmembra-se da obra originária, não sendo um direito exclusivo do autor.
- **Direito de retirada**: é a faculdade do autor de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem.
- **Direito de acesso**: é a faculdade do autor de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontra legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio de processo fotográfico ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memória de forma que cause o menor inconveniente possível a seu detentor, que, em todo caso, será indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado.

Retomando a natureza jurídica dos direitos morais de autor, que são relacionados como direitos de personalidade. Mas nem todas as características dos direitos de personalidade serão paliçadas aos direitos morais de autor, pois o surgimento destes subordina-se ao implemento de condição suspensiva: a criação. Assim, só adquirirão os direitos morais de autor aqueles que exteriorizarem suas criações. São características dos direitos morais de autor:

- **Extrapatrimonialidade**: é a impossibilidade dos direitos morais de autor serem traduzidos em valor econômico, dinheiro.
- **Eficácia absoluta**: os direitos morais de autor podem ser oponíveis *erga omnes*, ou seja, pode ser oposto pelo autor a qualquer um que ameace, tente ou efetivamente viole seus direitos morais.
- **Indisponibilidade**: relaciona-se à impossibilidade do autor de dispor dos direitos morais de autor, seja a título gratuito ou oneroso. São, portanto, inalienáveis e irrenunciáveis, como preceitua o art. 27 da LDA.

Art. 27. Os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis.

- **Intransmissibilidade**: não é característica que atinge todos os direitos morais na legislação brasileira. Segundo o art. 24 da LDA, transmitem-se aos sucessores do autor:
 - o direito à autoria
 - o direito ao nome
 - o direito ao inédito
 - o direito à integridade da obra

Os demais direitos morais de autor são considerados intransmissíveis. No entanto, há que se questionar o texto legal, pois o que se transfere não é o direito autoral, mas a legitimidade para seu exercício ou defesa. Desse modo, transmite-se aos herdeiros do autor a defesa dos direitos autorais.

- **Imprescritibilidade**: o não exercício das faculdades morais autorais não gera sua perda pelo autor nem sua aquisição por terceiros. É importante distinguir a imprescritibilidade do direito moral de autor da prescritibilidade de sua pretensão. Assim, o autor nunca perderá o direito de exigir de seu editor o respeito ao texto original apresentado, contudo a pretensão à reparação por perdas e danos pela alteração não autorizada do texto original prescreve no prazo fixado em lei. Como a LDA não prevê prazo prescricional para essa pretensão, prescreverá em 3 anos, como disposto no art. 206, §3º, inciso V, do C/C.
- **Preeminência**: os direitos morais de autor são preeminentes, porque prevalecem se em conflito com as demais espécies de direitos subjetivos,

conforme previsto expressamente na LDA para os casos de direito de acesso, de retirada e de modificação da obra. O legítimo possuidor da obra não pode se opor ao exercício do direito moral do autor, cabendo-lhe apenas pleitear prévia indenização.

b) Direitos patrimoniais: assegurados no art. 5º, inciso XXVII, da CR/88 e previstos no art. 28 da LDA (Lei 9610/98). Garante aos autores o direito de explorarem economicamente suas criações intelectuais, através da publicação utilização ou reprodução delas. São prerrogativas de cunho pecuniário, manifestando-se com a comunicação ao público. Muitas são as modalidades de utilização da criação e o art. 29 prevê uma série delas de forma exemplificativa.

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

Art. 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica.

Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como:

I - a reprodução parcial ou integral;

II - a edição;

III - a adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras transformações;

IV - a tradução para qualquer idioma;

V - a inclusão em fonograma ou produção audiovisual;

VI - a distribuição, quando não intrínseca ao contrato firmado pelo autor com terceiros para uso ou exploração da obra;

VII - a distribuição para oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para percebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, e nos casos em que o acesso às obras ou produções se faça por qualquer sistema que importe em pagamento pelo usuário;

VIII - a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica, mediante:

a) representação, recitação ou declamação;

b) execução musical;

c) emprego de alto-falante ou de sistemas análogos;

- d) radiodifusão sonora ou televisiva;
 - e) captação de transmissão de radiodifusão em locais de frequência coletiva;
 - f) sonorização ambiental;
 - g) a exibição audiovisual, cinematográfica ou por processo assemelhado;
 - h) emprego de satélites artificiais;
 - i) emprego de sistemas óticos, fios telefônicos ou não, cabos de qualquer tipo e meios de comunicação similares que venham a ser adotados;
 - j) exposição de obras de artes plásticas e figurativas;
- IX - a inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, a microfilmagem e as demais formas de arquivamento do gênero;
- X - quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas.

São características dos direitos patrimoniais de autor:

- **Transmissibilidade:** os direitos patrimoniais são transmissíveis por ato *inter vivos* ou *causa mortis*. Isso se dá porque o objetivo do direito patrimonial de autor é garantir-lhe o exclusivo de exploração econômica da obra.

OBS: DIREITO DE SEQUÊNCIA – art. 38 da LDA

Além dos royalties (são os direitos creditícios decorrentes do exercício do direito autoral, ou seja, remuneração do autor) contratados, cabe ao autor o direito de perceber no mínimo 5% sobre o aumento do preço verificável em cada revenda da obra. A valorização da obra é verificada pela diferença entre o preço da última venda e daquela imediatamente precedente.

Art. 38. O autor tem o direito, irrenunciável e inalienável, de perceber, no mínimo, cinco por cento sobre o aumento do preço eventualmente verificável em cada revenda de obra de arte ou manuscrito, sendo originais, que houver alienado.

Parágrafo único. Caso o autor não perceba o seu direito de sequência no ato da revenda, o vendedor é considerado depositário da quantia a ele devida, salvo se a operação for realizada por leiloeiro, quando será este o depositário.

- **Temporalidade e domínio público:** via de regra, em nosso ordenamento, os direitos patrimoniais perduram por 70 anos, contados do dia 1º de janeiro do ano subsequente ao falecimento do autor.

Art. 41. Os direitos patrimoniais do autor perduram por setenta anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil.

Parágrafo único. Aplica-se às obras póstumas o prazo de proteção a que alude o *caput* deste artigo.

Art. 42. Quando a obra literária, artística ou científica realizada em co-autoria for indivisível, o prazo previsto no artigo anterior será contado da morte do último dos co-autores sobreviventes.

Parágrafo único. Acrescer-se-ão aos dos sobreviventes os direitos do co-autor que falecer sem sucessores.

Art. 43. Será de setenta anos o prazo de proteção aos direitos patrimoniais sobre as obras anônimas ou pseudônimas, contado de 1º de janeiro do ano imediatamente posterior ao da primeira publicação.

Parágrafo único. Aplicar-se-á o disposto no art. 41 e seu parágrafo único, sempre que o autor se der a conhecer antes do termo do prazo previsto no *caput* deste artigo.

Com o domínio público a obra passa a pertencer à civilização humana. Pode ser analisado de modo:

- **Originário:** quando a proteção sequer chegar a ser concedida. Ex: obras de autor desconhecido.
- **Derivado:** quando decorrer o prazo de proteção acima descrito ou quando o autor falecer, e não deixar herdeiros.

OBS: o domínio público atinge os direitos patrimoniais e alguns dos direitos morais de autor, mantendo incólumes os direitos morais à autoria e à integridade da obra.

- **Economicidade:** o direito patrimonial do autor é a projeção econômica da criação, isto é, a exclusividade do autor de explorar economicamente sua obra.

Assim, a violação do direito autoral implica ameaça à exclusividade do autor de obter vantagens patrimoniais decorrentes da utilização da obra. A finalidade é impedir que haja concorrência ao autor na exploração econômica da obra. Se não há prejuízo patrimonial, não há violação. Desse modo, a utilização privada, desde que não importe realização de cópias é livre (art. 46, II, da LDA).

O ILÍCITO AUTORAL:

O ato ilícito, fato jurídico humano, que afronta o Direito, é a fonte geradora da responsabilidade civil, relacionando-se intimamente com o descumprimento de um dever jurídico preexistente.

Para San Tiago Dantas “*o ilícito é a transgressão de um dever jurídico. Não há definição mais satisfatória para o ilícito civil*” (apud CAVALIERI, 2007, p. 9)

Essa violação a um dever jurídico abarca a possibilidade de 2 juízos de valor:

- 1) sobre o caráter social ou anti-social do ato, que é aceito ou não pela sociedade;
- 2) sobre a conduta do agente, sua vontade, na sua dimensão ético-jurídica.

Leonardo Macedo Poli alude à 2 modalidades de ato ilícito autoral:

OBS: o Direito Autoral incide sobre a forma representativa da criação intelectual e não sobre seu conteúdo (idéia), pois a criatividade e o desenvolvimento social devem ser estimulados. O Direito não conseguiria aprisionar a idéia, simplesmente por ela ser imaterial, pertencente à realidade psíquica

1) **Ilícito absoluto:** aquele previsto no art. 186 do C/C, em que há violação de direitos patrimoniais e morais de autor, de modo EXTRACONTRATUAL. Ele comporta duas modalidades de violação:

a) **contrafação de direitos autorais:** caracteriza-se pela utilização de obra alheia sem autorização do autor, por qualquer modalidade. É conceituada pela LDA como a simples reprodução não autorizada da obra no art. 5º, VII:

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, considera-se:

VII - contrafação - a reprodução não autorizada;

Ocorre que tal conceito é restritivo, pois a contrafação é percebida sempre que há utilização não autorizada da criação, conforme todas as hipóteses previstas no art. 29 da LDA, e não somente reprodução.

Inclui-se aqui o **PLÁGIO**, que é a situação de utilização não autorizada da obra original, retocando-a, de maneira a parecer obra nova, não constituindo criação intelectual nova. É a apropriação ilícita e dissimulada da individualidade de obra já existente. **Relaciona-se com a violação de direitos patrimoniais de autor.**

O plágio se diferencia das demais espécies de modificação não autorizadas das obras preexistentes, pelo fato de que a atividade do plagiário não constitui, necessariamente, criação intelectual nova, faltando-lhe criatividade, pois o que há é mera simulação de criatividade.

Contudo, não há plágio se, embora haja semelhanças ou coincidências, as obras possuírem individualidade própria. Portanto, haverá plágio somente quando houver a apropriação ilícita e dissimulada da individualidade de obra preexistente.

É importante ressaltar que algumas obras derivadas (obras que são produzidas com base em outras, as originárias), tais como as paródias e as paráfrases, previstas no art. 47 da Lei 9610/98 (LDA), a apropriação da individualidade da obra preexistente é lícita, autorizada por lei e independe da autorização do autor da obra originária.

Art. 47. São livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe implicarem descrédito.

Isso ocorre porque nessas obras derivadas, o caráter criativo tem que estar presente sempre, ensejando a produção de nova obra intelectual, baseada numa obra originária que concedeu um tema para ser trabalhado.

Além disso, a licitude dessas obras derivadas (paródia e paráfrase) se ampara no princípio constitucional da livre manifestação do pensamento que garante a liberdade do debate científico-cultural, com a finalidade de construir conhecimento.

A apropriação ilícita da individualidade de uma obra protegida (plágio) pode ser:

- **Total**: é a apropriação da totalidade da individualidade de uma obra; possui muita relevância jurídica.
- **Parcial**: ocorre a apropriação ilícita de um conjunto considerável de elementos da obra preexistente.

b) **usurpação de obra alheia**: caracteriza-se pela mera cópia servil da obra intelectual, que foi divulgada sem indicação do nome do autor (usurpação negativa) ou com falsa menção de autoria (usurpação positiva). Relaciona-se com a violação de direito moral de autor, especificamente com o direito à paternidade.

2) **Ilícito relativo**: é aquele relacionado à prática de ato de que o agente deveria ter-se omitido em decorrência de uma relação obrigacional. Refere-se à impossibilidade dolosa ou culposa do cumprimento de determinada obrigação. Ele deriva da culpa CONTRATUAL, ensejando a instauração de procedimentos judiciais cabíveis para o descumprimento das obrigações em geral.

Assim, o ilícito autoral é caracterizado pelo desrespeito a um direito autoral moral ou patrimonial (ao qual corresponde o dever jurídico de respeito a ele), que pode ocorrer dentro de um contrato – ilícito relativo - (falta de remuneração pela cessão de direito autoral, extrapolação do número de exemplares permitidos, etc) ou de modo extracontratual – ilícito absoluto - (reprodução de obra sem autorização).

A violação de direitos conexos também caracterizaria ato ilícito e geraria a responsabilidade civil, mas não se trata de ato ilícito autoral, pois os direitos conexos são somente a eles equiparados.

OBRA E EXEMPLAR

A exteriorização da obra não se restringe à idéia de divulgação ou fixação, pois ela pode ser exteriorizada sem ser divulgada ou fixada. Desse modo, a proteção autoral incide sobre a obra em si e não sobre o exemplar.

A obra intelectual merecedora de proteção autoral não precisa, necessariamente, possuir um corpo material, palpável, mas no mínimo um corpo imaterial, abstrato, pois a idéia deve tomar forma para ser protegida.

Algumas teorias, ao longo da história, tentaram delimitar o objeto da obra intelectual:

Teoria Materialista: no início, a tutela autoral surgiu como proteção ao corpo físico da obra, ou seja, o EXEMPLAR, visto que, naquela época, era difícil verificar a separação entre o corpo material e o imaterial da obra.

Teoria Mista: com a invenção da imprensa, em 1455, por Gutemberg, houve a migração da tutela autoral do corpo material para o imaterial da obra, possibilitando a multiplicação da obra em exemplares e criando a necessidade de entendê-la como objeto distinto do suporte em que é fixada. Há o predomínio da idéia de obra intelectual como abstração formal (incorpórea) que é fixada em um suporte material (corpóreo). A obra intelectual é entendida como um conjunto composto por um corpo mecânico (material) e por um corpo místico (imaterial). O corpo místico seria a abstração formal e o corpo mecânico o suporte material em que a obra é exteriorizada. Essa teoria preconizava a indissociabilidade entre o corpo mecânico e o corpo místico da obra, uma vez que a criação deveria ser vista como uma unidade orgânica.

Teoria Imaterialista: a obra seria a abstração intelectual formal. O corpo mecânico não seria elemento essencial da obra, mas instrumento de sua representação, circulação e distribuição, que teria existência e seria identificável independentemente de seu suporte. O corpo mecânico é condicionado pelo avanço tecnológico; quanto mais limitada a tecnologia, mais limitada é a maneira de representar a criação do espírito.

De fato, a tecnologia digital proporcionou a separação da obra do suporte que tradicionalmente a receberia. A representatividade da criação intelectual não se limita mais a um corpo mecânico específico.

A teoria imaterialista é mais contemporânea, pois explica algumas situações que a realidade digital evidencia, tais como:

- a multiplicação da obra em vários exemplares não retira sua identidade;
- uma única obra pode ser exteriorizada em suportes materiais diversos;
- a obra pode ser fixada em suportes digitais intangíveis;
- qualquer espécie de obra pode ser representada por uma combinação digital o que favorece sua transformação, multiplicação e propicia sua fixação em suportes variados;
- a proteção autoral independe da fixação da obra em um suporte material;
- pode-se verificar a ocorrência de plágio mesmo em relação aos gêneros diversos que se utilizam de suportes materiais distintos (obra literária e obra cinematográfica).

Apesar da obra ter se desvinculado de seu suporte, o Direito Autoral ainda se mantém atrelado à concepção materialista. A licença de uso da obra é muitas vezes considerada como mera licença de uso do exemplar. Se o usuário perder ou deteriorar a obra, o uso ficará impossibilitado.

Assim, medidas de segurança que poderiam ser tomadas pelo usuário como a microfilmagem, arquivamento digital e cópia de uso, muitas vezes são consideradas como violações de direitos autorais, pois o usuário estaria modificando o suporte material da obra, com a finalidade não de burlar a lei, mas de se prevenir de danos que poderia vir a sofrer em caso de perda ou deterioração do seu exemplar da obra.

OBRAS DIGITAIS

A última questão referente à exteriorização da obra intelectual diz respeito à utilização da tecnologia digital, que se baseia na utilização de um código binário, sequência de dígitos, para representar qualquer quantidade e espécie de informação. Trata-se de um tipo de codificação da informação.

A tecnologia digital diminui consideravelmente a quantidade de informação necessária para a representação (digital) da obra, uma vez que textos, sons e imagens podem ser fixados e transmitidos em uma mesma mídia (multimídia). Um dos efeitos da utilização dessa tecnologia é produção de cópias idênticas à obra original.

São conseqüências da tecnologia digital no campo dos direitos autorais:

- maior facilidade e velocidade na transmissão de informações e distribuição de obras;
- maior facilidade na manipulação e no tratamento da informação;
- surgimento de novas categorias de obras intelectuais, como a obra multimídia, os programas de computador, as bases de dados eletrônicas, etc;
- aparecimento de uma nova técnica de criação ou exteriorização de obras;
- nascimento de novas maneiras de utilização das obras, tais como a transmissão digital, a comunicação virtual, armazenamento de dados, entre outras;
- possibilidade de interatividade do usuário com a obra;

A digitalização das obras pode gerar diversas questões relativas à utilização e exteriorização das obras. Mas será estudado, por ora, aquilo que se refere às criações informáticas, indagando se elas podem ou não ser consideradas obras intelectuais, merecendo, portanto, a proteção autoral.

A tarefa é analisar se a tecnologia digital pode ser instrumento de exteriorização das obras. Nesse contexto, pode-se dizer que a digitalização fixa a obra intelectual em um suporte digital, que pode ter a finalidade de exteriorizá-la ou de utilizá-la. Dessa forma, tem-se a digitalização:

- **Originária**: a obra é criada e exteriorizada através da mídia digital;
- **Superveniente**: a obra é criada, exteriorizada através de qualquer forma de expressão da realidade (escrita ou visual, por exemplo), para depois ser digitalizada.

De qualquer modo, uma vez digitalizada, a obra adentra no mundo informático e será utilizada de várias maneiras, que escapam aos conceitos tradicionais do Direito Autoral. Isso porque esse ramo do Direito não foi pensado para a tecnologia.

O tratamento dado à utilização digital das obras pela LDA é insuficiente, restringindo-se a estender a proteção autoral à utilização digital das obras, encaixando-a na hipótese genérica prevista no art. 29, X, o que demanda um tratamento específico e diferenciado sobre o tema.

Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como:

X - quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas.

Caso essa situação perdure, as obras tecnodigitais permanecerão à margem do Direito Autoral, ou se consolidará a invasão da esfera privada do usuário pelo titular de direitos autorais.

Uma solução plausível para a gestão de direitos autorais na Internet tem sido as *clearinghouses*, que buscam controlar e taxar o acesso às obras disponíveis na *internet* a partir do acesso ao banco de dados em que estiverem arquivadas.

Há 3 correntes que tentam solucionar os problemas decorrentes da utilização digital de obras:

- **Corrente neoliberal**: acredita que o Direito Autoral clássico é perfeitamente aplicável ao mundo digital, necessitando apenas de ajustes para reforçar as prerrogativas dos titulares de direitos autorais.
- **Corrente minimalista**: afirma que no ambiente digital é mais importante assegurar o direito à informação do usuário do que o direito do autor, que teria suas prerrogativas reduzidas. É influenciada pela crença de que a *internet* é terra sem lei.
- **Corrente eclética**: defende a idéia da busca do equilíbrio entre os interesses do autor e os interesses do usuário, em que o Direito Autoral englobaria também as obras tecnodigitais, sem prejudicar os direitos daquele que utiliza a obra.

No entanto, não há como negar que a tecnologia digital possa ser utilizada como ferramenta ou técnica a serviço da criação, pois ela seria aplicada somente na última fase, quando da exteriorização da obra.

A obra intelectual, enquanto elemento da cultura, utilizou os instrumentos de comunicação disponibilizados em cada época para promover sua exteriorização.

Inicialmente, a criação serviu-se das vias oral e gestual, seguindo pelas formas de representação das idéias, tais como os desenhos, os hieróglifos, a música, passando, na atualidade, à representação digital.

Outra solução para dirimir os conflitos sobre a utilização da tecnologia digital e a tutela autoral seria o *creative commons*, padrão de licenciamento, sem fins lucrativos, que visa conjugar uma ampla distribuição do conhecimento com a exploração comercial da obra, ou seja, tem-se a união entre a liberdade de acesso e a geração de receitas para o autor.

Nesse contexto contemporâneo de inovação tecnológica, as licenças *Creative Commons* são consideradas instrumentos de viabilidade dos direitos autorais em sede digital. Defende-se a idéia de que essas licenças não entram em conflito com os direitos autorais, pelo contrário, elas são um mecanismo de efetivação da Lei 9610/98 na *internet*, uma vez que ambos buscam incentivar a criatividade e a produção de conhecimento, promovendo maior desenvolvimento social.

A Responsabilidade Civil por violação dos direitos autorais:

A responsabilidade civil por violação ao direito autoral pode ocorrer de modo cumulado, sucessivo ou independente das demais responsabilidades penal e administrativa.

Art. 101. As sanções civis de que trata este Capítulo aplicam-se sem prejuízo das penas cabíveis.

A função da responsabilidade civil é restabelecer o equilíbrio jurídico econômico existente anteriormente entre o agente e a vítima, obrigando o causador do dano autoral a repará-lo através de uma indenização fixada de modo proporcional ao dano suportado.

Nesse tópico aborda-se a responsabilidade civil por dano a direito autoral em razão de simples violação da lei, ou seja, a RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL, já que para a responsabilidade contratual por violação de direitos autorais não se aplica as normas específicas constantes na LDA, mas sim as normas constantes na fonte da relação obrigacional preexistente, ou seja, o contrato.

Sempre que houver lesão a direito de autor, o titular pode optar por vários tipos de tutelas civis, sem prejuízo das demais:

1) exigir a cessação da conduta violadora e impor abstenção em relação a perturbações futuras. São exemplos previstos no art. 102 e 106 da LDA:

Art. 102. O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada, poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização cabível.

Art. 106. A sentença condenatória poderá determinar a destruição de todos os exemplares ilícitos, bem como as matrizes, moldes, negativos e demais elementos utilizados para praticar o ilícito civil, assim como a perda de máquinas, equipamentos e insumos destinados a tal fim ou, servindo eles unicamente para o fim ilícito, sua destruição.

2) caso estas providências não sejam suficientes, pode o titular requerer o restabelecimento do equilíbrio existente anteriormente através da indenização.

Na situação da responsabilidade extracontratual ou aquiliana, que visa combater o ilícito absoluto, segundo Sergio Cavalieri Filho:

“Haverá o dever de indenizar sempre que for violado o direito do autor em qualquer dos seus aspectos. Indenização por dano material se o causador do dano obtiver proveito econômico com a obra do autor sem a sua autorização ou participação; indenização por dano moral se a agressão for contra os direitos morais do autor; indenização por danos morais e patrimoniais se ambos os direitos forem violados. Já se firmou a jurisprudência, como não poderia deixar de ser, no sentido de cumulare-se as indenizações por dano material e moral ocorrendo ofensa a ambos os direitos do autor.”(CAVALIERI FILHO, 2001, p.03).

Segundo Poli, “a teoria subjetivista da responsabilidade civil foi uma vez mais consagrada como cláusula geral de responsabilidade, a teor no que prescreve o art. 186 do Código Civil” (POLI, 2008, p. 59)

O mesmo autor informa que a teoria da responsabilidade objetiva decorre:

- De expressa previsão legal ou;
- Da natureza de risco da atividade desenvolvida pelo autor do dano.

Desse modo, Poli prega que “a melhor hermenêutica parece ser a de se aplicar a cláusula geral subjetiva à responsabilidade civil por violação de direitos autorais, condicionando-se sua objetivação à análise casuística”. (POLI, 2008, p. 60).

Ascensão afirma que “*não há nenhuma responsabilidade objetiva em matéria de Direito de Autor. Só se indenizam danos ilicitamente causados*”. (ASCENSÃO, 2007, p. 542).

REFERÊNCIAS

ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. 754 p.

BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual: Tomo I*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 1079 p.

BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de Autor*. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. 188 p.

CAVALIERI FILHO, Sérgio. *Direito autoral e responsabilidade civil*. Revista da EMERJ, Rio de Janeiro, vol. 04, n. 13, p. 43-50, 2001. Disponível em: <http://www.focusfoto.com.br/direito.autoral.fotografia.htm>. Acesso em 24/09/2011.

CAVALIERI FILHO, Sérgio. *Programa de Responsabilidade Civil*. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2007. 561 p.

FIÚZA, César. Crise e interpretação no direito civil da escola da exegese às teorias da argumentação. In: FIÚZA, César; SÁ, Maria de Fátima Freire de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira (Coords.). *Direito Civil – atualidades*. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 23-59.

FIÚZA, César. *Direito Civil: curso completo*. 14 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2010. 1123 p.

GONÇALVES, Carlos Roberto. *Direito Civil Brasileiro: responsabilidade civil*. São Paulo: Saraiva, 2010, v. 04. 559 p.

POLI, Leonardo Macedo. A funcionalização do Direito Autoral: Limitações à Autonomia Privada do titular de Direitos Autorais. In: FIÚZA, César; SÁ, Maria de Fátima Freire de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira (Coords.). *Direito Civil – atualidades II*. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 315 - 338.

POLI, Leonardo Macedo. Análise teórica e prática do monopólio de exploração econômica de obras intelectuais. In: FIÚZA, César; SÁ, Maria de Fátima Freire de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira (Coords.). *Direito Civil – atualidades IV*. Belo Horizonte: Del Rey, 2010, p. 537 - 561.

POLI, Leonardo Macedo. *Direito Autoral: parte geral*. Belo Horizonte: Del Rey, 2008. 171 p.